

1500049-54.2021.8.26.0123

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Éverton Willian Pona

Comarca: Capão Bonito

Foro: Foro de Capão Bonito

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Capão Bonito

Foro de Capão Bonito

2ª Vara

Rua Rafael Machado, 50, Capão Bonito-SP - cep 18304-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500049-54.2021.8.26.0123 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500049-54.2021.8.26.0123

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2024606/2021 - DEL.POL.CAPÃO

BONITO, 15906236 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 166/21/414 - DEL.POL.CAPÃO BONITO, 2024606 - DEL.POL.CAPÃO BONITO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

FABRICIO DE ALMEIDA MORAES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Éverton Willian Pona

Vistos.

1 RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública, sob o rito ordinário, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de FABRICIO DE ALMEIDA MORAES, já devidamente qualificado nos autos, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Segundo consta na denúncia (fls. 165-167), no dia 27 de janeiro de 2021, por volta de 14:45 horas, na Rua José Maria Lopes Teixeira, nº 145, Vila Aparecida, nesta

cidade e comarca de Capão Bonito, FABRICIO guardava e mantinha em depósito drogas, consistentes em 20 (vinte) porções de "crack" (cocaína), com peso bruto de 2,29g (dois gramas e vinte e nove centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o Ministério Público, o réu guardava e mantinha em depósito as drogas acima descritas, com a manifesta intenção de entregá-las ao consumo de terceiros, fato este que chegou ao conhecimento da Polícia Civil, que passou a realizar campanhas pelas imediações.

Durante as campanhas, os investigadores confirmaram as suspeitas, notando intensa movimentação no local, típica do tráfico de drogas.

Na data dos fatos, os policiais deliberaram por entrar no imóvel, tendo em vista que o portão estava aberto, onde localizaram, na mesa da cozinha, 20 porções de "crack", todas embaladas e prontas para a venda, além da quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais) em dinheiro.

Após, deslocaram-se até o quarto onde estavam FABRICIO e sua companheira Evelyn, momento em que o réu assumiu a propriedade das drogas e confessou a traficância. Diante as circunstâncias da prisão, da quantidade de drogas apreendidas e a forma que estavam embaladas não resta dúvida para o Ministério Público de que os entorpecentes se destinavam ao tráfico de drogas.

Acompanharam os autos deste processo o recebimento da denúncia às fls. 141-143, seguindo-se a regular citação do réu às fls. 171, com posterior apresentação de resposta à acusação (fls. 157-159).

Realizou-se audiência de instrução na qual foram ouvidas as testemunhas e interrogado o réu. Nada foi requerido na fase no art. 402, do Código de Processo Penal.

Em alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa requer a absolvição do réu, por não existir prova suficiente para a condenação, subsidiariamente, requer seja reconhecida a prática do crime em sua modalidade privilegiada, nos termos do Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. Passo à fundamentação e decisão.

2 FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação penal instaurada para a apuração do delito de tráfico de entorpecentes.

Não há preliminares a serem apreciadas ou nulidades a serem declaradas. O mérito há de ser conhecido.

2.1 Sobre o delito de tráfico de entorpecentes

A materialidade da conduta imputada ao réu encontra-se devidamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 22-24) auto de exibição/apreensão (fls. 25-26), auto de constatação preliminar (fls. 27), laudo pericial exame químico-toxicológico positivo para cocaína (fls. 130-132) e pela prova oral colhida em juízo.

Em relação à autoria, de se considerar que o réu, na fase policial, disse que: faz um mês que mora no endereço Rua Jose Maria Lopes Teixeira, 145; mora com sua companheira Evelyn e seu filho de um ano e oito meses; não possui passagens criminais; está desempregado; mantém a sua casa com a ajuda de seus pais; sua mãe paga o aluguel de duzentos e cinquenta reais; sua mãe e seu pai ajudam nas coisas de casa; tem o auxílio emergencial do governo para se manter; é usuário de crack; na data dos fatos, estava dormindo e os policiais chegaram na sua casa e o abordaram; os policiais acharam em cima da mesa a "dura"; se refere como "dura" a droga crack; seu celular e o dinheiro; foi algemado e trazido para a Delegacia; um pouco das drogas pega pra vender e o restante pega pra usar; começou esses dias a vender; vendia por cinco reais cada pedra; as pessoas passavam na rua e perguntavam se tinha "dura"; vendia uma ou duas e depois já comprava pão com o dinheiro; comprava pronta; comprava a droga em ribeirão grande. (fls. 07). Apesar de intimado, não compareceu em juízo e teve sua revelia decretada.

A testemunha, Alessandro Corbage de Sá, policial civil, ouvido em solo policial, disse que: é investigador de polícia civil; há alguns dias juntamente com o policial civil Silvio estavam realizando campana na Rua Jose Maria Lopes Teixeira, próximo ao numeral 145, no bairro Vila Aparecida; havia informações de moradores do bairro, inconformados com a traficância ocorrendo a luz do dia nesta rua; durante a campana por alguns dias visualizaram pessoas adentrando ao imóvel em referência, pessoas estas com características similares de usuários de drogas; na data do depoimento, durante a campana, notaram que mais pessoas continuavam e entrar no imóvel e logo saírem portando algo na mão; de longe era algo característico de ser substância entorpecente; tais pessoas não foram possíveis de serem abordadas em virtude da distância da campana; juntamente com o policial civil Silvio, entrou no imóvel; o portão era de latão e estava aberto; dentro da casa visualizaram de pronto na cozinha, exatamente em cima de uma mesa, porções de substância aparentemente crack, todas embaladas e prontas para a venda, além disso uma quantia em dinheiro; foram até o quarto e avistaram duas pessoas deitadas na cama e uma criança; os dois indivíduos foram abordados e qualificados como FABRICIO e Evelyn; o depoente indagou acerca das substâncias entorpecentes em cima da mesa e FABRICIO disse que realiza a traficância na sua casa, sendo dele a responsabilidade das drogas; o depoente indagou Evelyn que confirmou o alegado pelo FABRICIO; assim, deu voz de prisão para FABRICIO no artigo 33 da lei de drogas e conduziram as partes para a delegacia de polícia; as substâncias continham 20 pedras de substância aparentemente crack, R\$ 25,00 em notas miúdas de dois reais, algo que confirma serem oriundos do tráfico e um aparelho de telefone celular. FABRICIO foi algemado para manter sua integridade física. (fls. 03).

Em juízo relatou que: receberam denúncias de um indivíduo continuava a realizar o comércio de entorpecentes; em determinado dia tentaram abordar um dos usuários que havia comprado; FABRICIO entrou correndo na residência e resolveram adentrar; o imóvel era um conjugado e logo visualizaram as porções de crack na mesa da cozinha; FABRICIO já tinha se envolvido em uma ocorrência de tráfico há uns 15 dias anteriores; o companheiro do depoente comentou sobre essa ocorrência prévia e o réu disse que estava desempregado e precisava sustentar a família; não tinham mandado para entrar na residência mas estava caracterizada a situação de flagrância; ao que se recorda, no imóvel há apenas o bar e o "puxadinho" onde o réu residia; o réu era conhecido como "Gibi"; na ocorrência anterior que o depoente menciona o réu foi conduzido à Delegacia e estava respondendo em liberdade.

A testemunha, Silvio Almeida De Oliveira, policial civil, ouvido em solo policial, disse que: é policial civil; há vários dias estava em campana pelo local dos fatos, pois havia notícias de populares que no local estava ocorrendo a traficância; durante os dias visualizou pessoas diversas adentrando à residência com características similares de usuários de entorpecentes; na data do depoimento, também notou que alguns indivíduos adentraram ao imóvel e saíram de lá portando algo na mão, característico de substância entorpecente, contudo, não foi possível abordar tais pessoas em virtude da distância da campana; adentraram ao imóvel que se localiza na Rua Jose Maria Lopes Teixeira, numeral 145, Vila Aparecida, local este controlado pelo tráfico de drogas; que ao adentrarem no imóvel depararam-se de imediato na cozinha, em cima da mesa, 20 porções de substância aparentemente crack, prontas para a venda e uma quantia em dinheiro; que no quarto encontraram duas pessoas, sendo um casal deitado na cama e uma criança; que os mesmos foram abordados e qualificados como sendo FABRICIO e Evelyn; indagado FABRICIO acerca das substâncias o mesmo confessou de imediato que realiza a traficância na sua casa; o que foi corroborado pela sua companheira; assim, o policial Alessandro deu voz de prisão a FABRICIO e conduziram as partes para a delegacia de polícia; as partes não reagiram à prisão, contudo FABRICIO foi algemado para preservar sua integridade. (fls. 03).

Em juízo relatou que: estavam há alguns dias em campana em vista de denúncias indicando que o réu estava comercializando drogas; se não se engana, o réu foi preso por tráfico em uma situação anterior; na data em questão visualizaram algumas pessoas chegarem até o local para a compra do entorpecentes; tentaram abordar o indivíduo mas ele se evadiu; resolveram fazer a abordagem e viram que FABRICIO

entrou correndo na residência; acharam, na cozinha, 20 porções de crack embaladas e pronta para a comercialização; o réu admitiu que estava desempregado e promovia o tráfico para sustentar a família; no mesmo lugar, numa portinha ao lado, funcionava um bar utilizado também para o tráfico.

No que tange ao depoimento de policiais, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os milicianos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprir em seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escoreitamente.

Importante ressaltar que o policial é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal". (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

No caso sob análise, a atuação dos agentes policiais revestiu-se de legalidade, ao menos pelo que se extrai dos autos, pois não há nenhuma demonstração concreta de irregularidade ou arguição que tenha fundamento a ponto de mudar o quadro formado. Os depoimentos dos policiais foram seguros, coesos e harmônicos entre si, dotados de credibilidade e com força probatória. Nada existe de concreto nos autos a indicar que os policiais ouvidos em juízo estivessem tentando incriminar falsamente o réu, atribuindo-lhe o falso cometimento de um delito.

Do contexto probatório dos autos extrai-se que os policiais receberam informações de que o réu estaria traficando e, após observarem a movimentação típica dessa prática na residência do réu, um "puxadinho" ao lado de uma "portinha" em que já funcionou um suposto bar, decidiram por realizar a abordagem.

Tentaram abordar o usuário que havia recém saído do local, porém ele logrou êxito e se evadiu. Viram, então, FABRICIO correndo para dentro da residência e o seguiram. No local, com apenas dois ou três cômodos, pelo que se recordaram os policiais, FABRICIO estava se dirigindo ao quarto e, de plano, foi possível constatar os entorpecentes (20 pedras de crack), na mesa da cozinha, devidamente embalados e prontos para a entrega para consumo.

As testemunhas fizeram menção à uma abordagem prévia de FABRICIO pelo mesmo delito. Analisando-se a folha de antecedentes (fls. 201-202), observa-se que ele já foi autuado em 2019 também por ocorrência ligada ao tráfico de entorpecentes e, depois dos fatos apurados nestes autos, foi novamente preso em flagrante em 20/05/2021, novamente pelo tráfico (autos nº. 1501616-23.2021). Embora condenado em primeira instância, foi absolvido pelo Tribunal de Justiça por falta de provas.

É possível, como destacou o Ministério Público, que as testemunhas policiais tenham se confundido com a cronologia das abordagens. Contudo, essa confusão em nada influência em relação aos fatos aqui apurados, em relação a cuja abordagem o depoimento das testemunhas Silvio e Alessandro é absolutamente coerente.

A suposta confusão de autoria suscitada pela Defesa em audiência igualmente não encontra espaço nos autos. A afirmação de que o apelido "Gibi" seria de outra pessoa, como afirma a Defesa, não tem qualquer respaldo nas provas dos autos. Mesmo o réu, quando ouvido na fase policial, não mencionou tal circunstância – segundo a Defesa, ele teria dito isso ao seu patrono.

Os depoimentos das testemunhas prestados na fase policial não mencionaram o apelido. Embora seja do conhecimento dos policiais, em razão da rotina de sua

atuação, sequer constou no boletim de ocorrência. Logo, não seria possível ao réu afirmar que estava sendo confundido a partir do seu apelido quando essa circunstância sequer havia aparecido nos autos até a audiência de instrução. O réu foi preso em flagrante. Não há qualquer possibilidade de estar sendo confundido.

Portanto, não há dúvida sobre a ocorrência do fato delituoso e de sua autoria.

O réu, de forma consciente e espontânea, trazia consigo drogas, para fins de entrega ao consumo de terceiros, consistentes em 20 pedras de "crack" com massa bruta de 1,61 gramas; sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conduta que se amolda formalmente à previsão abstrata do art. 33, "caput", da Lei 11.343/06. Restando preenchida a tipicidade formal.

Caracterizada, pois, a tipicidade formal objetiva, imperioso destacar a presença, também, da tipicidade material, ante a efetiva violação do bem jurídico protegido pela norma, bem como, dos elementos subjetivos do tipo. O réu agiu com dolo, nas modalidades cognitiva e volitiva, pois evidente tratar-se de conduta deliberada. O fato é típico, portanto.

Outrossim, não se verificam presentes quaisquer das causas excludentes da antijuridicidade da conduta, previstas no art. 23, do Código Penal. O fato descrito é, assim, típico e ilícito.

Além disso, o réu possui plena capacidade penal e pode ser responsabilizado por seus atos. É penalmente imputável e possui condições de compreender a ilicitude de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Segundo se observa nos autos, possuía conhecimento suficiente, à época dos fatos, para perceber a ilegalidade de sua ação e agir, se assim quisesse de outra forma. Optou pela conduta ilícita quando dele era exigível comportamento diverso. Por tais razões, a sua conduta é culpável.

Desse modo, por se tratar de fato típico, antijurídico e culpável, ausentes quaisquer causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou de extinção da punibilidade, mostra-se imperiosa a condenação do réu FABRICIO DE ALMEIDA MORAES nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

2.2 Individualização da pena

Fixadas tais premissas, passa-se à individualização da pena, nos termos do art. 59, do Código Penal e art. 42, da Lei de Drogas. Adota-se, para a dosimetria da pena, o sistema trifásico previsto no art. 68, do Código Penal.

2.2.1 Dosimetria da pena

Na primeira fase da dosimetria a culpabilidade mostra-se normal e inerente ao delito; não constam antecedentes; não há informações sobre a conduta social ou sobre a personalidade do réu; os motivos são inerentes ao delito, assim como as circunstâncias e as consequências. Não se observa, por fim, qualquer contribuição do comportamento da vítima.

No caso de tráfico de drogas, deverá ser considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (art. 42, da Lei de Drogas). Quanto à natureza, observa-se ter sido apreendida crack. Há maior reprovabilidade quanto a essa circunstância.

Crack, especialmente, apresenta potencial viciante maior, gerando com facilidade a drogadição. Além disso, o crack causa dependência extremamente forte e produz efeito social devastador, facilmente observado nos grandes centros urbanos, que sofrem com a concentração de viciados em referida substância em determinadas regiões, gerando, além de insegurança para a população ao redor de tais conglomerados de viciados, a reiteração de pequenas práticas delitivas praticadas por tais pessoas no intento de sustentar o vício.

Em recente reportagem veiculada em meio de comunicação de credibilidade nacional, afirmou-se que "pequenos municípios do país começam a viver o processo chamado de interiorização do crack. A droga é distribuída a partir das capitais e causa uma

série de impactos sociais em locais com menos recursos”, como o caso de Capão Bonito.

Prossegue a reportagem afirmando que o crack “atinge pelo menos 86% dos municípios brasileiros, de acordo com levantamento do Observatório do Crack, criado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios). Segundo os dados da entidade, 4.813 dos 5.568 municípios relataram ter registrado problemas ligados ao crack. Em mais de 20% deles, o nível de gravidade desses problemas é classificado como alto” e reproduz fala da pesquisadora e consultora do Observatório do Crack, Mariana Boff Barreto a qual afirma que “o crack é uma droga de alto poder ofensivo e um combustível para vários tipos de violência” e “Nessas cidades, cresceu muito o número de furtos, roubo, latrocínios, crimes também contra o próprio dependente, ou seja, vários tipos de violência correlacionada”.

Por essas razões, em razão não apenas do seu potencial viciante e destrutivo para a saúde do usuário, mas também pelas consequências sociais que a droga provoca, com aumento da criminalidade, o tráfico do crack deve receber reprimenda maior. Assim, considero negativa a natureza das substâncias.

Em relação à quantidade, foram apreendidos 20 (vinte) porções de “crack” (cocaína), com peso bruto de 2,29 gramas. Não há no caso, desborde do tipo penal em razão dessa quantidade.

Em relação ao quantum do aumento nesta fase da dosimetria prevalece na jurisprudência, em razão da ausência de previsão específica na legislação, competir ao magistrado sopesar as especificidades do caso concreto e atribuir o devido valor a cada uma das circunstâncias judiciais. Confira-se:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O CP não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 107.860, rel. min. Rosa Weber, 1ª T, DJE de 25-9-2012.)

O STF submete a legalidade da pena ao fundamentado exame judicial das circunstâncias do delito. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação e ponderação dos efeitos da sanção, embasado nas peculiaridades do caso concreto, e no senso de realidade do órgão sentenciante. O art. 59 do CP confere ao juízo sentenciante o poder-dever de estabelecer uma reprimenda apta à prevenção e simultaneamente à reprovação do delito, sempre atento o magistrado à concretude da causa. Sucede que, em situações como a retratada nos autos, o juiz sentenciante há de considerar parâmetros que são próprios da legislação de drogas. Parâmetros constantes do art. 42 da Lei 11.343/2006. Pelo que o caso é de calibração das balizas do art. 59 do CP com as circunstâncias listadas na pertinente legislação extravagante. No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, diante da natureza e da quantidade de droga apreendida. O que não discrepa da jurisprudência do STF (RHC 108.878, rel. min. Ayres Britto, 2ª T, DJE de 21-11-2011).

Em reflexão sobre a forma de atribuição do quantum atinente a cada circunstância judicial, este magistrado entende, em aperfeiçoamento a posicionamentos anteriores, que a majoração da pena nesta fase da dosimetria em um percentual fixo (1/6 ou 1/8) sobre a pena mínima abstrata prevista na legislação ignora por completo a previsão legislativa acerca do limite máximo da reprimenda estabelecido, tratando de forma igual crimes com gravidade distintas, o que, em última análise, viola o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).

Isso porque a individualização da pena apresenta-se em três momentos distintos: o legislativo (cominação abstrata da pena), com a fixação dos limites mínimo e máximo da pena; o judicial, com o estabelecimento da pena in concreto; e no momento da execução da pena, quando tem influência o comportamento individual do apenado para a concessão dos benefícios previstos na legislação.

A fase legislativa, de cominação abstrata da pena, representa a reprovabilidade do corpo social em relação à conduta tornada crime. Assim, no momento da aplicação, ignorar que crimes com a mesma pena base podem ostentar penas máximas distintas corresponde a sobrepor-se à reprovação da conduta externada pela sociedade por

intermédio dos legisladores.

Desse modo, por serem 10 as circunstâncias constantes no caput do art. 59, do CP, somadas, entende-se que o quantum a ser atribuído a cada uma delas é de, no mínimo, de 1/10 entre a diferença da pena mínima e máxima fixada para o delito. Contudo, forte na jurisprudência, as especificidades do caso autorizam ao magistrado a atribuir maior relevância a uma ou outra circunstância, desde que devidamente fundamentado.

Considerando que no presente caso reconheceu uma circunstância como negativa (a natureza da substância), acresço ao piso 1/10 da diferença entre o mínimo e o máximo abstratamente cominado ao delito e fixo a pena base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, em relação às agravantes e atenuantes, observa-se que há circunstância atenuante aplicável à hipótese, pois o agente era menor de 21 anos na data do fato (artigo 65, inciso I, primeira parte, do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena em 1/6, tornando a pena provisória em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, considerando a primariedade do réu, a ausência de maus antecedentes e ao fato de não integrar organização criminosa, aplico a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, diminuo a pena em 2/3. Portanto, torno definitiva a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

2.2.2 Regime inicial de cumprimento da pena

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário esclarecer que o réu foi condenado pelo delito de tráfico de drogas, o qual é equiparado ao hediondo e, por força do art. 2º, §1º, da Lei nº. 8.072/90, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da determinação por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, em 27/06/2012. Assim sendo, não há vedação à fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo a condenados por tráfico de drogas, consoante o entendimento do STF, por força da necessária individualização da pena, que implica na necessidade de se observarem as circunstâncias do caso concreto e de cada condenado.

Nos termos do art. 59, III, do Código Penal, considerando o requisito objetivo (a quantidade de pena fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão.), o fato de o réu ser reincidente e tendo em vista as circunstâncias judiciais (art. 33, §3º, do CP), a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente aberto.

2.2.3 Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis

No caso o réu foi condenado a pena inferior a 4 anos, satisfazendo o requisito objetivo. Além disso, o condenado não é reincidente e as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal não lhe foram desfavoráveis. Sua conduta não se mostra incompatível com a vida em sociedade, já que o crime não afrontou a integridade física de outrem, pelo que faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, do CP).

Tendo em vista a pena fixada, determino a substituição por duas restritivas de direitos consistente na prestação de serviço à comunidade (art. 44, §2º, do CP), a ser cumprida à razão de 1 hora por dia (art. 46, §3º, do CP), em entidade a ser estabelecida pelo juízo da execução, pelo prazo da condenação e prestação pecuniária de 1 salário mínimo vigente ao tempo dos fatos..

2.2.4 Fixação do valor do dia-multa

Em atendimento ao disposto no art. 49, §1º, do Código Penal, fixo valor do dia-multa em 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, pois não há nos autos informações sobre a condição financeira do réu.

2.2.5 Detração

A aplicação do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (detração a ser realizada pelo juiz na sentença) carece de uma melhor regulamentação, visto ser dispositivo assemelhado aos regramentos da progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais.

Nesse sentido, precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação Criminal – Receptação. Sentença condenatória. Recurso Defensivo pleiteando o reconhecimento da detração para fixar o regime aberto para cumprimento da pena. Materialidade e autoria provadas - Réu surpreendido na condução de veículo produto de furto - Depoimento do policial que merece credibilidade, sendo coeso e harmônico em relação ao conjunto probatório - Confissão judicial do réu que corrobora as demais provas produzidas em juízo - Manutenção da condenação de rigor - Dosimetria das penas - Pena-base fixada no mínimo legal - Manutenção da compensação da circunstância atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por ausência de reclamo Ministerial - Entendimento predominante no sentido de que a reincidência prepondera sobre a confissão, nos termos do art. 67, do Código Penal - Vedação da reforma tio in pejus - Penas inalteradas - Regime inicial semiaberto que se mantém em razão da reincidência registrada - Manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Detração da pena - questão que deve ser melhor analisada em sede de execução criminal - Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0068936-68.2016.8.26.0050; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/08/2017; Data de Registro: 18/08/2017)

Do teor do acórdão extrai-se:

No tocante a aplicação do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, determinando que o tempo da prisão provisória deva ser computado para fixação do regime inicial para o seu cumprimento, entendendo não ser possível sua aplicação, eis que inviável a análise de requisitos subjetivos [...].

No mesmo sentido, recente julgado da 8ª Câmara Criminal do Tribunal Bandeirante, na Apelação nº 016797-87.2012.8.26.048, Relator: Lauro Mens de Melo, donde se extrai que, "inicialmente, inviável entender-se que o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal pode ser considerado como alteração de regime inicial a partir de pena cumprida, funcionando como progressão indireta". Além disso, "trazer para o processo de conhecimento numerosos dados acerca da execução tumultuária o processo, tornaria a prestação jurisdicional confusa e mais demorada, o que certamente vai de encontro aos interesses da defesa".

Com efeito, a progressão do regime por este juízo, em decorrência de custódia cautelar, requer o acesso a dados pessoais do réu, como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os requisitos objetivo e subjetivo.

Ademais, a detração somente pode ser adequadamente apreciada pelo juízo da execução, que pode analisar todas as condenações do réu e evitar que o mesmo período de custódia cautelar seja utilizado para abatimento das penas em mais de um processo.

Tal análise deve ser feita no âmbito da execução penal, pelo que deixo de realizar a detração.

3 DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu FABRICIO DE ALMEIDA MORAES pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias-multa.

FIXO para ambos, o valor do dia-multa em 1/30 do maior salário mínimo vigente à

época dos fatos.

SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por DUAS restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo vigente à época dos fatos. CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP) e, com base no art. 15, III, da Constituição Federal, enquanto durarem os efeitos da condenação, DETERMINO a suspensão de seus direitos políticos.

4 DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 Prisão preventiva

O réu respondeu o processo em liberdade e a instrução está terminada. Não há, assim, risco de influência na produção de provas e na instrução criminal; a reincidência e as circunstâncias do crime demonstram a inexistência de conduta que ofereça risco à ordem pública e o réu apresenta endereço no distrito da culpa, com emprego fixo, pelo que não há perigo concreto de se evadir.

Ausentes, portanto, os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, DEIXO DE DECRETAR a segregação e concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

4.2 Decretação de perdimento dos valores apreendidos

Decreto o perdimento dos valores apreendidos às fls. 25-26 por ser produto de atividade criminosa.

4.3 Determinações finais e comunicações

Comunique-se a condenação ao IIRGD (art. 393, V, das NSCGJ) e, com o trânsito em julgado:

- a) Intime-se o réu para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias (art. 50, do CP e art. 480, das NSCGJ), bem como das custas judiciais no prazo de 60 dias (art. 480, §1º, das NSGCJ). Infrutífera a intimação ou não efetuado o pagamento da multa no prazo assinalado, extraia-se certidão da sentença nos termos do art. 480-A, das NSCGJ;
 - b) Oficie-se ao INI, ao IIRGD, à VEC e ao TRE (art. 398, II, das NSCGJ);
 - c) Expeça-se de guia de recolhimento definitiva ou oficie-se aditando a guia provisória (art. 472, das NSCGJ) e mandado de prisão;
 - d) Determino a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas e ainda não destruídas (art. 72, da Lei nº. 11.343/2006);
 - e) Comunique-se a SENAD, para o fim previsto no art. 63, §§ 2º e 4º, da Lei nº. 11.343/2006, remetendo relação dos bens e valores declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto aos bens, os locais em que se encontram e a entidade ou órgão em cujo poder estejam, para os fins de sua destinação nos termos da legislação vigente;
 - f) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados.
- Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Capão Bonito, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA